

1500109-10.2021.8.26.0452

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... que: receberam denúncia anônima de tráfico de drogas nas imediações do local dos fatos, uma barbearia/salão de cabeleireiro; ali se depararam com o acusado, que, ao visualizar a viatura policial, demonstrou nervosismo, correndo para dentro do estabelecimento comercial; na fuga, dispensou no chão quatro das porções de maconha apreendidas; dirigiram-se à residência do imputado, onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 13 de Maio, 476, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500109-10.2021.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500109-10.2021.8.26.0452

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3004061/2021 - DEL.POL.PIRAJU,

15692064 - DEL.POL.PIRAJU

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALEX SANDRO APARECIDO GALDINO DA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

Relatório dispensado (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/1.995). Fundamento e decido.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Passo à análise do mérito da causa.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 1/3), pelo termo circunstanciado (fls. 4/6), pelos autos de exibição e apreensão da droga (fls. 7/8) e pelos laudos de constatação preliminar (fls. 9/10) e de exame químico-toxicológico (fls. 19/21), cujo resultado foi positivo para maconha (tetrahidrocannabinol), droga proscriita pela Portaria ANVISA 344/1998 e alterações posteriores.

A autoria também é certa e recai sobre o réu, despontando da prova oral produzida nos autos.

Os policiais militares Carlos Eduardo dos Santos e Rogério Leme de Freitas narraram, em uníssono, que: receberam denúncia anônima de tráfico de drogas nas imediações do local dos fatos, uma barbearia/salão de cabeleireiro; ali se depararam com o acusado, que, ao visualizar a viatura policial, demonstrou nervosismo, correndo para dentro do estabelecimento comercial; na fuga, dispensou no chão quatro das porções de maconha apreendidas; dirigiram-se à residência do imputado, onde foram recebidos pela sua esposa, Bruna, a qual lhes informou que aquele era usuário de cocaína; em vistoria ao imóvel, franqueada pela mulher, encontraram mais três porções de maconha e três pinos vazios de cocaína (fl. 2 e mídia da audiência).

Em solo policial, o réu confessou a prática delitiva (fl. 4). Em juízo, não foi interrogado, porquanto revel.

Como se vê, os seguros, claros e congruentes testemunhos dos agentes públicos, que têm eficácia probatória amplamente reconhecida pela jurisprudência de há muito consolidada pelos tribunais superiores - desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu (como na espécie, até porque não o conheciam) -, aliados à confissão extrajudicial do réu, formam quadro probatório convincente e bastante para lastrear o edito condenatório. Não descuro que “a confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2012). A dizer: “apresenta pouco valor probatório, apenas podendo ser utilizada como fundamento para a condenação se corroborada por provas contundentes que tenham sido colhidas em juízo sob o crivo do contraditório” (AVENA, Norberto, Processo Penal,

13. ed., Rio de Janeiro Forense; MÉTODO, 2021, p. 590). Assento, isto sim, ser justamente esse o caso dos autos, em que a confissão extrajudicial do réu está em sintonia com os harmônicos depoimentos das testemunhas. A par disso, a defesa não comprovou o fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva alegado (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP). Quanto à qualificação jurídico-legal dos fatos, atento ao objeto material do delito (diminuta quantidade de maconha: 11,810g), ao desvalor da ação (local e condições em que se desenvolveu a conduta) e ao próprio agente do fato (circunstâncias sociais e pessoais não desabonadoras, inexistência de maiores informações sobre a conduta e ausência de antecedentes do agente, ao menos por ocasião da prática dos fatos ora sob apuração), critérios que devem ser sopesados pelo juiz no mister de determinar se a droga se destinava, ou não, ao consumo pessoal (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), tenho que nada aponta para a traficância, de modo que a conduta se amolda, mesmo, à definição jurídica estampada na denúncia (art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

Também não há que se falar em inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, tampouco em atipicidade da conduta, sob a argumentação de que se está diante de autolesão. Cuida-se de crime vago, que vulnera bem jurídico difuso (saúde pública) e tem como sujeito passivo a coletividade, e não o próprio indivíduo que consome drogas, não se cogitando, pois, de autolesão, na esteira do que leciona RENATO BRASILEIRO DE LIMA, invocando a jurisprudência relativa ao tema:

Apesar da despenalização produzida pela Lei nº 11.343/06 em relação ao porte de drogas para consumo pessoal, afastando-se a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, a legislação brasileira ainda incrimina a conduta do indivíduo que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para muitos, essa opção pela punição do porte de drogas para consumo pessoal seria incompatível com a Constituição Federal, seja por violar o direito à intimidade e à vida privada (CF, art. 5º, X), seja por se mostrar incompatível com o princípio da ofensividade. (...).

A despeito desse entendimento, ainda prevalece a orientação no sentido de que a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal não é incompatível com a

Constituição Federal. Por mais que o agente traga a droga consigo para consumo pessoal, não se pode perder de vista que a sua conduta coloca em risco a saúde pública, porquanto representa um risco potencial à difusão do consumo de drogas. De mais a mais, mesmo que indiretamente, outros bens jurídicos além da saúde pública são lesionados em virtude dessa conduta. Com efeito, não é incomum que o usuário-dependente pratique outros crimes para sustentar seu vício. Ademais, a aquisição de drogas por parte do usuário serve como forte estímulo para a prática do tráfico de drogas. Noutro giro, por mais que seja verdade que a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal não venha surtindo o efeito desejado, nem por isso se pode cogitar da possibilidade de renunciarmos à tutela do direito penal para coibir tal conduta. Fosse assim, condutas delituosas diversas como homicídios, latrocínios e roubos também deveriam ser descriminalizadas, porquanto a utilização do Direito Penal como instrumento para coibir tais condutas delituosas também não vêm surtindo os efeitos desejados, infelizmente.

Prova disso, na lição de Mendonça e Carvalho, é a situação das “Cracolândias” espalhadas por todo o território nacional, onde grupos de cidadãos transformam-se em flagelados por conta da dependência química gerada pelo uso descontrolado de drogas, passando a praticar uma infinidade de crimes de modo a sustentar o vício. Para os autores, “embora se saiba que, para essas hipóteses, é mais útil a intervenção estatal a partir de políticas públicas voltadas ao tratamento e principalmente à reinserção social dos dependentes, visando trazê-los de volta ao seio social, não se pode privar o Estado de todos os meios preventivos e repressivos dessa verdadeira catástrofe social, dentre os quais a perspectiva de punição penal ao usuário”.

De todo modo, convém destacar que a matéria deve ser apreciada em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Consoante notícia de 22 de dezembro de 2011, o Plenário do Supremo admitiu a existência de repercussão geral em Recurso Extraordinário (RE 635.659) no qual um acusado foi condenado à pena de 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade pelo Juizado Especial Criminal de Diadema/SP. A Defensoria Pública de São Paulo questiona a constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas à luz do direito à intimidade e à vida privada e diante do princípio da ofensividade. (Legislação criminal especial comentada: volume único – 9. ed. – Salvador: JusPODIVM, 2021, pp. 1035/1036).

Como o aludido julgamento do RE 635.659 ainda não foi concluído, e por se tratar de análise em controle difuso de constitucionalidade, ainda que seja reconhecida a incompatibilidade do dispositivo com a ordem constitucional, é necessário que haja suspensão da norma pelo Senado Federal (art. 52, X, da CF), caso em que, somente então, a decisão vinculará juízes e Tribunais, pois o Pretório Excelso tem afastado a tese da abstrativização do controle difuso.

De resto, descabe a aplicação do princípio da insignificância à espécie. Apesar de a quantidade de droga apreendida não ser considerável, esta circunstância já serve de base para a configuração do crime em comento; se houvesse grande quantia do estupefaciente, estar-se-ia, por suposto, diante do crime de tráfico de drogas. Ademais, pela própria natureza do delito de posse de droga para consumo pessoal – crime de perigo abstrato –, afigura-se inviável o acolhimento da tese da insignificância, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC n. 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/5/2013).

2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 620033 MG 2014/0317728-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015); e RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes.

2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes.

3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos.

4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC: 37094 MG 2013/0118921-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014).

Logo, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, tampouco extintivas da punibilidade, a conduta é típica e antijurídica, incidindo, pois, as sanções cominadas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O preceito secundário da norma penal descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 prevê a possibilidade de o magistrado aplicar as seguintes penas: advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (incisos I, II e III). Tais penas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como ser substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor (art. 27 da mesma lei). Nessa tarefa, o aplicador deve levar em consideração a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), sem embargo da utilização subsidiária do quanto disposto no art. 59 do CP.

No tocante à duração das penas, a advertência é imediata e instantânea, ao passo que as outras duas serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses (art. 28, § 3º, da LD), tratando-se de acusado primário, ou de 10 (dez) meses, tratando-se de reincidente (art. 28, § 4º, da LD).

Consoante entendimento recente do STJ, externado pela 6ª Turma no REsp 1.771.304-ES, sob a relatoria do eminente Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.12.2019, ao qual me filio, a reincidência, para fins de aplicação do art. 28, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente possibilidade de aplicação das penas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, é apenas a específica. Assentou a Corte Superior de Justiça que a melhor exegese, segundo a interpretação

topográfica, essencial à hermenêutica, é a de que os parágrafos em foco não são unidades autônomas, estando vinculados ao caput do artigo a que se referem.

Joeirados esses critérios, observo que a ínfima quantidade de drogas não enseja maior reprovação penal, e não há informações precisas sobre a personalidade e conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, grau de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, LVII da CF, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançada em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja, ainda, pela peculiaridade de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito, consoante consagrado pela jurisprudência pátria. O réu possui uma condenação por tráfico de drogas (fls. 45/48) que encarna mau antecedente. Os

motivos não merecem maior reprovação, por serem ínsitos à espécie criminosa. As circunstâncias e as consequências do crime não destoaram do ordinário. Não há elementos nos autos para se avaliar a conduta social e a personalidade do réu. Por fim, em razão da natureza do crime, não há que se falar em comportamento da vítima. Diante do antecedente desabonador, entendo que a medida de advertência, aplicada de forma isolada, não surte o efeito esperado, de maneira que não é suficiente para alcançar a finalidade da norma penal. Reputo ser mais adequada à prevenção e repressão do delito, dentre as duas outras cominadas pelo art. 28 da LD, a medida de prestação de serviços à comunidade.

No tocante à duração da sanção penal, o acusado já foi, como dito, condenado definitivamente pela prática de tráfico de drogas. Na esteira da motivação supra, não é reincidente específico, aplicando-se o art. 28, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, a ditar a aplicação da penalidade pelo prazo de até 5 (cinco) meses. Mercê do antecedente desabonador, aplico a medida no patamar máximo de 5 (cinco) meses. Consigno que o descumprimento injustificado da medida imposta sujeitará o condenado à admoestação verbal e, sucessivamente, ao pagamento de multa, tudo na forma do § 6º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado ALEX SANDRO APARECIDO GALDINO DA CUNHA, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses.

Diante da característica da pena aplicada, assiste ao réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Condeno o sentenciado também ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do CPP). Entretanto, considerando que foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do CPC.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), porque se está diante de crime vago, e não houve pedido expresso da acusação nesse particular.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Expeça-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado: (a) determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06; (b) caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25, do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (c) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; (d) expeça-se a guia de execução, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (e) lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD; e (f) ofícios de praxe;

P. I. C. Diligências necessárias.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Piraju, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA